Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
1ª Vara Cível da Comarca de Uruguaiana

Rua General Hipólito, 3392 - Bairro: São João - CEP: 97502441 - Fone: (55) 3412-1410 - Email: fruruguaia1vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5006803-06.2021.8.21.0037/RS

AUTOR: ANA MARIA CASTRO GONZALEZ
ADVOGADO: WILLIAM MARTINS PEREIRA GALLINO (OAB RS050330)

RÉU: IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

VISTOS.

I - RELATÓRIO:

ANA MARIA CASTRO GONZALEZ ajuizou ação de obrigação de fazer em face de **IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL**, ambos qualificados nos autos. Relatou ser portadora de Leucemia mieloide crônica (CID-C921), com mutação FLT3 positiva, necessitando do uso do fármaco RYDAPT 25 MG – MIDOSTAURINA, posologia de 02CP 12/H do D8 ao D21 de cada ciclo de tratamento (pelo menos 4) totalizando 56 unidades para cada ciclo, resultando em 224 unidades a contemplar "pelo menos 4 ciclos", podendo necessitar de extensão do tratamento, cujo custo orçado para o período inicial perfaz a quantia de R$ 177.099,94 reais (cento e setenta e sete mil e noventa e nove reais com noventa e quatro centavos). Discorreu sobre o seu direito. Diante do exposto, requereu, em juízo de cognição sumária, e ao final, o fornecimento do tratamento postulado. Pugnou pela concessão de gratuidade de justiça. Instruiu a inicial com documentos.

Concedidos à parte autora o benefício da gratuidade de justiça (evento 3, DESPADEC1) e a tutela de urgência pleiteada (evento 8, DESPADEC1).

Citado, o demandado apresentou contestação (evento 26, CONT1). Em suas razões, afirmou que o medicamento postulado não está previsto nas recomendações do Protocolo Oncológico do Instituto para o tratamento de Leucemia Mieloide Crônica, sustentando que não pode ser compelido à cobertura de um tratamento que excede o previsto por seu regulamento, de custo elevado, sob pena de ser levado à insolvência, prejudicando a coletividade associada, mormente por não haver no caso em testilha qualquer indicativo da ineficácia dos medicamentos oferecidos pela autarquia. Argumentou que a parte autora pretende um tratamento diferenciado, o qual não será estendido aos demais segurados, o que implica em clara afronta ao princípio da isonomia. Deduziu, ainda, que não consta na bula emitida pela ANVISA autorização para o uso do medicamento requerido para o tratamento da Leucemia Mieloide Crônica, sendo a parte autora diagnosticada com leucemia crônica e não aguda, com o que se considera utilização *off label* ou experimental, vedado pelo STF. Por fim, postulou a total improcedência da ação e, em caso de condenação, *ad argumentandum tantum*, requereu seja observada a denominação comum brasileira do fármaco pleiteado.

Houve réplica (evento 30, PET1).

As partes não demonstraram interesse na produção de outras provas (evento 32, DESPADEC1).

A seguir, vieram conclusos para julgamento.

II – FUNDAMENTAÇÃO:

O feito comporta julgamento antecipado do pedido, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, por tratar de matéria que prescinde de produção de prova em audiência para a solução das questões controvertidas.

Dispõem os artigos 1º e 2º da Lei Complementar nº 12.134/2004:

Art. 1º - Fica reestruturado o Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul, seus dependentes e pensionistas, denominado IPE-SAÚDE, tendo como gestor o IPERGS - Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, autarquia criada pelo Decreto nº 4.842, de 8 de agosto de 1931, segundo os ditames da presente Lei Complementar, resoluções e regulamentos próprios. § 1º - O Sistema de que trata o "caput" engloba um conjunto de ações visando à prevenção de doenças, à promoção, educação e assistência à saúde de seus usuários, constituído pelo Plano Principal, também denominado IPE-SAÚDE e por Planos Suplementares e Complementares, que já existam ou que venham a ser criados, para o aprimoramento, qualificação, maior abrangência e efetividade da cobertura prestada. § 2º - A normatização do Sistema IPE-SAÚDE far-se-á pela edição de leis, decretos e resoluções do Órgão Gestor. ***Art. 2º - Integram o Plano IPE-SAÚDE os atendimentos médicos, hospitalares, os atos necessários ao diagnóstico e ao tratamento, bem como ações de prevenção da doença e à promoção da saúde.*** *grifei*

Na hipótese em tela, a probabilidade do direito invocado emana diretamente do artigo 196 da Constituição da República que consagra a todos o direito à **saúde** e o correlato dever do Estado latu sensu de garanti-lo mediante o acesso universal às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

Ademais, o documento encartado no **evento 6, DOC2** evidencia que a autora formulou pedido administrativo para o fornecimento do fármaco ora requerido na via administrativa.

No entanto, teve seu pedido indeferido ("não autorizado"), sob a alegação de que o medicamento postulado não está previsto nas atuais recomendações técnicas em oncologia do IPE-SAÚDE (outros 2, evento 6).

Por conseguinte, percebe-se que o plano de saúde não invocou como motivo para o indeferimento a exclusão expressa da cobertura o que configura o que torna descabido a negativa porquanto não é dado ao plano escolher o tratamento.

A negativa exarada sob o argumento de que o tratamento não é previsto nas recomendações técnicas, mostra-se infundada. Afinal, ainda que o contrato de assistência à saúde firmado entre as partes não contenha cobertura específica para o tratamento pleiteado, o Código de Defesa do Consumidor, ao qual está submetido, nos termos da Súmula 469 do STJ, determina, em seu art. 47, que as cláusulas sejam interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Também incide na espécie o disposto no art. 51, IV, § 1°, II, do Código de Defesa do Consumidor, sendo nula, portanto, eventual cláusula que coloque o consumidor em desvantagem ou restrinja direitos inerentes à natureza do ajuste.

Disso se conclui que os planos de saúde podem estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, mas não lhes cabe determinar ou limitar o tipo de tratamento que será prescrito - incumbência do médico que assiste o paciente.

Nesse sentido seguem precedentes do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

> *"REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. IPE-SAUDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NEGATIVA DE DISPENSA PELO **PLANO**. IMPOSSIBILIDADE. O art. 2º da Lei Complementar nº 12.134/04 dispõe que "integram o **plano** de **saúde** atendimentos médicos, hospitalares, atos necessários ao diagnóstico e ao tratamento, assim como ações de prevenção da doença e promoção à saúde". **Portanto, não é facultado ao plano de saúde negar o fornecimento do medicamento para o tratamento da parte autora, sob a justificativa de não fazer parte da cobertura, pois não cabe ao IPE-Saúde selecionar o tratamento dispensado**. SENTENÇA MANTIDA, EM REMESSA NECESSÁRIA.(Remessa Necessária Cível, Nº 70084744036, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em: 26-01-2021)" (grifei)*

> *"APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. IPE-SAÚDE. CONVENIADA PORTADORA DE CÂNCER DE MAMA. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTOS: PERJETA 840MG E 420MG, HERCEPTIN 516MG E TAXOTERE 132 75MG. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. - O art. 2º da Lei Complementar n.º 12.134/04, que instituiu o IPE-SAÚDE, dispõe que integram o **plano** de saúde atendimentos médicos, hospitalares, atos necessários ao diagnóstico e ao tratamento, assim como ações de prevenção da doença e promoção à saúde. **Não há dúvidas, portanto, acerca da responsabilidade quanto ao fornecimento de qualquer tipo de tratamento, desimportando as razões de negativa do plano de saúde, pois lhe falece legitimidade para selecionar o tipo de tratamento dispensado ao segurado**. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70075073718, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 23/11/2017)." (grifei)*

Do mesmo modo, a alegação declinada pela parte ré de que o tratamento em análise não estaria prescrito na bula, portanto, não autorizado pela ANVISA para finalidade do caso *in concreto*, caracterizando uso *off label*, não a exime de fornecer o tratamento.

O STJ possui orientação no sentido de que a cobertura contratual não pode excluir a dispensação de medicamento de natureza experimental ou *off label* (sem previsão de utilização específica em bula do medicamento), a despeito do disposto no art. 20, § 1º, inciso I, alínea *c*, da Resolução Normativa nº 428/2017 da ANS, por lhe estar vedada a limitação de tratamentos a que o paciente pode se submeter:

> *PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.*
> *AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO.*
> *USO OFF LABEL. RECUSA INDEVIDA. ROL DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS PELA ANS. EXEMPLIFICATIVO. RECUSA INDEVIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 568 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. INVIABILIDADE DE REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. INDENIZAÇÃO. VALOR QUE NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.*
> *1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.*
> *2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas, sendo-lhes vedado, no entanto, limitar os tratamentos a serem realizados. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico que ministra o tratamento (off label).*
> *3. Esta Terceira Turma tem reiterado o entendimento de que o rol de procedimentos da ANS tem caráter exemplificativo, de modo que a ausência de previsão no referido rol não afasta do plano de saúde a obrigação de custear procedimento/medicamento necessário ao tratamento de moléstia contratualmente coberta.*
> *4. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, o descumprimento contratual por parte da operadora de saúde, que culmina em negativa de cobertura para procedimento de saúde, enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente, o que foi constatado pela Corte de origem no caso concreto.*
> *5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a redução ou majoração do quantum indenizatório é possível*

somente em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a indenização arbitrada, sob pena de incidência do óbice da Súmula nº 7 do STJ. Proporcionalidade e razoabilidade observadas no caso dos autos, a justificar a manutenção do quantum indenizatório.
6. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1590645/PE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021)

Portanto, ainda que o tratamento prescrito pelo médico assistente tenha indicação *off label* de tratamento, revela-se abusiva a exclusão de sua cobertura.

A corroborar, colaciono jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado acerca do tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE FIBROSE PULMONAR PROGRESSIVA. MEDICAMENTO NINTEDANIBE (OFEV). ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS TAXATIVO. DUT RELATIVIZADA SOB FUNDAMENTO RELEVANTE. 1) Embora atualmente não haja uma pacificação na jurisprudência, vez que a Terceira Turma da Corte Superior adota posição de que o rol da ANS é meramente exemplificativo, neste momento, após estudos da legislação e casos, está Câmara concluiu por rever posicionamento e alinhar os julgados ao entendimento sufragado no REsp 1.733.013/PR, no sentido de que o rol é taxativo, sobretudo considerando que o referido rol da autarquia regulamentadora não visa privilegiar nenhuma das partes, mas apenas harmonizar a relação contratual com substrato em diretrizes técnicas relevantes. 2) Não obstante, no julgamento do REsp 1.733.013, balizador do novel entendimento, restou expressamente consignado que, sob pena de violação do próprio princípio do acesso à justiça e diante do risco do estabelecimento ilegal de presunção absoluta (juris et de jure) de higidez dos atos da Administração Pública, com a adotação do entendimento do Rol Taxativo da ANS não se está a dizer que não possam existir situações pontuais em que o julgador, amparado de informações técnicas relevantes, submetidas ao contraditório, em decisão racionalmente fundamentada, venha determinar o fornecimento de certa cobertura que constate ser efetivamente imprescindível, com supedâneo em medicina baseada em evidência (clínica). 3) Caso dos autos em que, a despeito de a cobertura do medicamento Nintendanibe (OFEV), nas Diretrizes estabelecidas no Rol de Procedimentos da RN 465/2021, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ser apenas devida quando houver diagnóstico de câncer pulmonar, restou devidamente demonstrado que o tratamento prescrito pelo médico pneumologista do autor, com medicamento ambulatorial anti-fibrótico, o qual é preconizado pelas diretrizes nacionais e internacionais para fibrose pulmonar, com o objetivo de evitar progressão da doença e seus sintomas de falta de ar, tosse e insuficiência respiratória, mediante o medicamento Nintedanibe, é o único aprovado no Brasil pelas agências reguladoras. 4) Configurado caso de exceção à regra descrita no julgado REsp 1.733.013, vez que o quadro clínico do autor se traduz em situação pontual, que diante das informações técnicas relevantes contidas nos autos, impõe o fornecimento da cobertura do fármaco postulado, por ser imprescindível o tratamento em questão e estar baseada em evidência (clínica). 5) Outrossim, o egrégio STJ possui orientação no sentido de que a cobertura contratual não pode excluir a dispensação de medicamento de natureza experimental ou off label (sem previsão de utilização específica em bula do medicamento), a despeito do disposto no art. 20, § 1º, inciso I, alínea c, da Resolução Normativa nº 428/2017 da ANS, por lhe estar vedada a limitação de tratamentos a que o paciente pode se submeter. POR MAIORIA, DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.(Agravo de Instrumento, Nº 50589261020228217000, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 30-06-2022)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE CARCINOMA GÁSTRICO. MEDICAMENTO PEMBROLIZUMABE (KEYTRDA®). USO OFF LABEL. ROL DA ANS TAXATIVO, QUE NÃO SE APLICA PARA OS MEDICAMENTOS ANTINEOPLÁSICOS PRESCRITOS SOB FUNDAMENTO RELEVANTE. RECONHECIDO O DEVER DE COBERTURA. AUSENTE DANO MORAL, DIANTE DA NEGATIVA JUSTIFICADA. 1) Ocorrendo a morte de qualquer das partes do processo, haverá a sucessão pelo espólio ou sucessores, observado o disposto no artigo 313, §§ 1º e 2º, do CPC. Preliminar acolhida. 2) Tratando-se de contrato regulamentado, devem ser observadas as coberturas mínimas definidas na Resolução Normativa nº 428/2017, atual RN 465/2021, da Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS), que apresenta Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, a qual não pode prever aquelas excetuadas no artigo 10 da Lei nº 9.656/98 e, também, não pode excluir ou mitigar as hipóteses do artigo 12 do mesmo diploma legal. 3) Embora atualmente não haja uma pacificação na jurisprudência, vez que a Terceira Turma da Corte Superior adota posição de que o rol da ANS é meramente exemplificativo, neste momento, após estudos da legislação e casos, está câmara decidiu por e alinhar os julgados ao entendimento sufragado no REsp 1.733.013/PR, de que o rol da ANS é taxativo, sobretudo considerando que o rol da autarquia regulamentadora não visa privilegiar nenhuma das partes, mas apenas harmonizar a relação contratual com substrato em diretrizes técnicas relevantes. 4) Não obstante, no julgamento do REsp 1.733.013, balizador do novel entendimento, atestou que, sob pena de violação do próprio princípio do acesso à justiça e diante do risco do estabelecimento ilegal de presunção absoluta (juris et de jure) de higidez dos atos da Administração Pública, com a adotação do entendimento do Rol Taxativo da ANS não se está a dizer que não possam existir situações pontuais em que o julgador, amparado de informações técnicas relevantes, submetidas ao contraditório, em decisão racionalmente fundamentada - venha determinar o fornecimento de certa cobertura que constate ser efetivamente imprescindível, com supedâneo em medicina baseada em evidência (clínica). 4) Caso dos autos em que, além de se tratar de medicamento indicado pela médica assistente para o tratamento de carcinoma gástrico, CID C16.9, o fármaco Pembrolizumabe está devidamente registrado na ANVISA, a qual publicou, no Diário Oficial da União de 18/10/20211, nova indicação para o medicamento, incluindo os casos de câncer gástrico. 5) Afora isso, o egrégio STJ possui orientação no sentido de que a cobertura contratual não pode

excluir a dispensação de medicamento de natureza experimental ou off label (sem previsão de utilização específica em bula do medicamento), a despeito do disposto no art. 20, § 1º, inciso I, alínea c, da Resolução Normativa nº 428/2017 da ANS, por lhe estar vedada a limitação de tratamentos a que o paciente pode se submete. 6) A recusa injustificada, que configura comportamento abusivo, capaz de ensejar a obrigação de reparar danos de ordem moral, consiste naquela negativa de cobertura de tratamento legal, a que a operadora do plano de saúde está contratualmente obrigada a garantir. 7) No caso telado, a negativa ofertada pela ré foi fundamentada na Diretriz de Utilização da ANS, vez que, quando do pedido de cobertura do medicamento em questão sua indicação era off-label, e, nesse contexto, a operadora do plano de saúde, em atenção ao contrato, não estava obrigada a custear o tratamento. Justificável, portanto, a negativa de fornecimento do medicamento, devendo ser mantida a improcedência do pedido de indenização por danos morais. 8) Verba honorária que deve ser fixada consoante parâmetros nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, ainda que se trate de causa com valor elevado (Tema 1076 STJ). POR MAIORIA, DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA E, À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE RÉ.(Apelação Cível, Nº 50035778020218210008, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 03-06-2022)

Por fim, quanto ao pleito de observação da denominação comum brasileira do fármaco, conforme consta do receituário do evento 1, OUT5, o medicamento é único, não possuindo genérico ou similar, portanto inviável o acolhimento do referido pedido.

Sendo assim, pelos argumentos acima já expostos, imperiosa a procedência do pedido.

III – DISPOSITIVO:

Diante do exposto, torno definitiva a decisão liminar proferida, **JULGO PROCEDENTE** o pedido formulado **ANA MARIA CASTRO GONZAL** para **CONDENAR** o requerido I**PE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL** a fornecer o fármaco RYDAPT 25 MG – MIDOSTAURINA, nos termos do requerido na inicial.

A Fazenda Pública é isenta da Taxa Única de Serviços Judiciais.

Diante da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios em favor do procurador da parte autora, os quais arbitro em 10% sobre o valor atribuído à causa, de acordo com os parâmetros elencados no art. 85, § 3º, do CPC, considerando, para tanto, o trabalho realizado, o tempo de tramitação do feito e a natureza da demanda. Sobre os honorários incidirão correção monetária pelo IGP-M e juros de mora a partir do ajuizamento da ação, na forma do Enunciado de n.º 14 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Em caso de interposição de apelação, intime-se a parte recorrida para a apresentação de contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso seja suscitado, pela parte recorrida, em preliminar de contrarrazões, inconformismo contra decisões proferidas na fase de conhecimento não submetidas a agravo de instrumento, intime-se o recorrente para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas, nos termos do art. 1.009, §2º, do CPC.

Após, ao Ministério Público.

A seguir, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Não é caso de reexame necessário (art. 496, § 3º, inciso II, do CPC).

Com o trânsito em julgado e nada mais sendo requerido, arquivem-se com baixa.

Documento assinado eletronicamente por **RAMIÉLI MAGALHÃES SIQUEIRA, Juíza de Direito**, em 25/7/2022, às 15:29:8, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10022509009v15** e o código CRC **d7e6c8f0**.